

<제14장 정의행위.제10절 정의기간 중 대체근로의 제한>

[기출][2][2022-1-2]용역업체의 대체근로 저지행위에 대한 형사상 위법성 여부

《【문제1】 A공사는 국가의 도로를 관리하는 업무를 수행하는 공기업이다. B회사와 C회사는 시설관리용역업체이고, A공사와 청소용역계약을 체결하여, A공사의 본사에서 청소용역업무를 수행하고 있다. 甲과 乙은 B회사의 근로자로 각각 B회사 노동조합의 위원장과 사무국장이다. B회사 노동조합은 B회사와의 임금 등에 관한 단체교섭이 결렬되자 2022. 5. 관할 지방노동위원회에 조정을 신청하였고, 조정이 성립하지 않자 정의행위 찬반투표를 거쳐 2022. 6. 25. 파업에 돌입하였다. B회사 노동조합은 2022. 6. 25. A공사 본사 정문 앞을 집회장소로 신고하였으나, 신고된 장소에서 집회를 하지 않고 B회사의 근로자들에게도 평소 통행이 자유로운 A공사 본사의 본관과 옆 건물 사이의 인도에 모여서 함께 구호를 외치며 노동가를 제창하고, 설치된 확성기를 이용하여 1시간 동안 집회를 하였다. B회사 노동조합은 이 집회를 통해 B회사에 대하여 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. 또한 2022. 7. 1. 유사한 방식으로 B회사 노동조합은 동일한 장소에서 집회를 1시간 20분 동안 개최하며 임금인상, 성실교섭 등을 요구하였다. B회사 노동조합이 두 차례 집회를 개최하고 있을 때 A공사는 신고된 집회장소로 나가라고 수 차례 요구하였으나 B회사 노동조합은 이에 불응하였다. B회사 노동조합의 집회에서 시설물의 파괴나 폭력행위가 발생하지는 않았고, 이 집회로 인하여 A공사 직원들의 업무에 실질적으로 지장이 초래되지는 않았다. A공사는 본관 건물 지하에 B회사 노동조합의 활동을 보장하기 위하여 노동조합 사무실을 제공하여 왔다. 그리고 B회사 노동조합은 A공사 사업장 내에서 B회사와 단체교섭을 진행하였으며, 파업 기간 중에도 B회사 노동조합은 B회사와 교섭을 계속하여 왔다.

한편 C회사는 B회사 노동조합이 파업에 돌입하자 2022. 6. 25. 자신이 고용한 근로자 5명을 투입하여 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무를 수행하도록 하였다. 甲과 乙은 자신들이 하던 업무를 C회사 근로자들이 수행하고 있는 것을 발견하고, 이들 근로자들의 앞을 막은 채 청소를 그만두고 밖으로 나가라며 고함을 지르고, 청소를 하지 못하게 방해하였다. 甲과 乙은 또한 이들 근로자들이 각층에 수거해 놓았던 쓰레기를 건물복도에 버렸다. 甲과 乙의 행위로 인해 A공사 본사 본관 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고, A공사 직원들의 통행에 다소 불편을 초래하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A공사와 C회사는 甲과 乙의 C회사 근로자들에 대한 대체근로 저지행위가 형사적으로 위법하다고 주장한다. A공사와 C회사의 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 용역업체의 대체근로 저지행위에 대한 형사상 위법성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 C회사는 같은 시설관리용역업체 B회사의 파업으로 인한 공백을 메우기 위하여 자사 근로자들을 투입하여 A공사의 청소업무를 수행하게 하였는데, B회사의 노동조합 간부 甲과 乙은 이들의 앞을 막고 고함을 지르며 퇴거를 요구하였고, 각층에 모아둔 쓰레기를 건물 복도로 버려 청소업무를 방해하여, A공사와 C회사가 이 행위의 형사적 위법성을 주장하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <B회사 노동조합의 파업으로 중단된 청소용역업무를 수행하기 위해 C회사가 대체근로자를 투입한 행위가 대체근로에 해당하는지>, <B회사 노동조합인 甲과 乙이 C회사의 대체인력 투입을 저지하기 위해 앞을 막아서고 쓰레기를 복도에 버린 행위가 형법 제20조의 사회상규에 위배되지 않는 정당행위로서 위법성이 조각되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 관련한 판례법리를 검토하고 사안에 적용하여 A공사와 C회사의 주장의 정당성에 대하여 논한다.

II. 대체근로의 제한과 저지행위의 정당성 범위

1. 노조법상 대체근로의 제한 및 위법성

(1) 대체근로 제한의 취지

- “노동조합 및 노동관계조정법(이하 ‘노조법’) 제43조 제1항”은 사용자가 정의행위 기간 중 그 정의행위로 중단된 업무의 수행을 위하여 당해 사업과 관계없는 자를 채용 또는 대체할 수 없도록 규정한다. 이는 근로자의 단체행동권인 파업이 대체인력 사용으로 무력화되는 것을 방지하고 노사 힘의 균형을 유지하기 위한 강행규정이다.

(2) 원하청 관계에서의 대체근로 위법성

- “대체원”은 수급인의 파업으로 중단된 업무를 원청(도급인)이 다른 수급인이나 외부 인력을 대체 투입하여 수행하게 하는 것은 실질적으로 수급인 소속 근로자들의 정의행위를 무력화하므로 위법한 대체근로에 해당한다고 판시한다. 원청과 다른 수급인이 파업에 직·간접적으로 대항하여 인력을 대체하는 것 역시 “노조법 제43조” 위반의 효력을 면할 수 없다.

2. 대체근로 저지행위와 정당행위의 요건

(1) 실력행사의 허용성과 한계

- 사용자 또는 제3자가 위법한 대체근로를 단행하는 경우, 정의행위에 참가한 근로자들이 이를 저지하기 위해 상당한 정도의 실력을 행사하는 것은 정의행위가 실효를 거둘 수 있도록 하기 위해 인정된 정당행위(“형법 제20조”)로서 위법성이 조각된다.

(2) 사회상규상 정당성 판단 기준

- 위법한 대체근로 저지행위가 사회통념상 용인될 수 있는 정당행위에 해당하는지 여부는 저지행위의 경위, 목적, 수단과 방법, 그로 인한 결과, 폭력이나 파괴행위의 수반 여부 등을 종합적으로 고려하여 합리적·객관적으로 판단하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. C회사의 대체근로 투입의 위법성

- C회사는 B회사의 파업이 개시된 날 곧바로 B회사 근로자들의 기존 전담 업무인 화장실 청소 및 쓰레기 수거업무에 대체인력 5명을 투입하였다. 이는 B회사 근로자들의 파업 효과를 전면적으로 상쇄·무력화하기 위한 도구로 평가되므로, “노조법 제43조 제1항”을 위반한 명백히 위법한 대체근로의 투입에 해당한다.

2. 甲과 乙의 저지행위의 정당성 검토

(1) 저지 수단의 상당성

- 甲과 乙은 투입된 대체근로자들의 소속 및 정당한 근로 권한 등을 확인하는 과정에서 그들의 앞을 막아서고 고함을 치며 나가라고 요구하였다. 이러한 저지 방식은 신체에 직접적인 위해를 가하는 폭력이나 파괴행위, 협박 등의 위법한 물리력 행사에 나아가지 않은 소극적·방어적 실력행사에 해당하여 상당성이 인정된다.

(2) 쓰레기 투기 행위의 상당성

- 대체근로자들이 임의로 수거해 둔 쓰레기를 복도에 다시 버림으로써 건물의 미관이 일시적으로 훼손되고 통행에 불편을 준 행위는, 위법한 대체근로를 저지하기 위한 항의 과정에서 수반된 경미한 저항 행위에 불과하다. 시설관리권이나 업무 방해의 실질적인 해악 정도가 매우 미미하므로 사회통념상 허용되는 범위 내에 있다.

## IV. 결론

- C회사의 대체근로 투입 행위 자체가 위법하므로, 이에 대한 甲과 乙의 저지행위는 쟁의행위의 정당한 보호를 위한 상당한 범위의 실효행위이다. 따라서 甲과 乙의 행위는 형법 제20조의 정당행위에 해당하여 위법성이 조각되므로 형사상 범죄가 성립하지 않는다. 결론적으로 이들의 행위가 형사적으로 위법하다는 A공사와 C회사의 주장은 정당성이 없고 타당하지 않다.

<보충(반대의견) - A공사와 C회사의 주장 정당 : 용역업체의 대체근로 저지행위가 형사적으로 위법하다>

### I. 문제 제기

- 사안에서 C회사는 같은 시설관리용역업체 B회사의 파업으로 인한 공백을 메우기 위하여 자사 근로자들을 투입하여 A공사의 청소업무를 수행하게 하였는데, B회사의 노동조합 간부 甲과 乙은 이들의 앞을 막고 고함을 지르며 퇴거를 요구하였고, 각층에 모아둔 쓰레기를 건물 복도로 버려 청소업무를 방해하여, A공사와 C회사가 이 행위의 형사적 위법성을 주장하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <대체근로의 법적 허용범위와 그 전제하에서 노동조합의 저지행위가 정당한 쟁의행위로 보호될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 A공사와 C회사의 주장의 정당성에 관하여 논한다.

## II. 대체근로의 허용범위

### 1. 대체근로 일반론

- 근로자들의 파업권은 헌법상 보장된 권리이지만, 사용자가 파업으로 인한 업무 공백을 최소화하기 위하여 일정한 범위에서 대체근로자를 활용하는 것은 원칙적으로 허용된다. 다만 "노동조합법 제43조"는 쟁의행위 기간 중 사용자가 신규 채용이나 하도급 등을 통한 대체근로 투입을 금지하고 있다. 이는 근로자의 쟁의행위 효과를 무력화하는 것을 방지하기 위함이다.

### 2. 계속적 · 통상적 외주와의 구별

- "판례"에 따르면, 사용자가 평소부터 특정 업무를 외주화하여 외부업체 근로자가 해당 업무를 담당하고 있었다면, 파업기간 중에도 그러한 외주계약에 따른 근로제공은 금지되는 대체근로에 해당하지 않는다. 즉, 평소부터 업무 일부를 외주업체가 담당하고 있었다면 이는 신규대체근로가 아니라 정상적 계약관계의 이행에 불과하다.

### 3. 대체근로 저지행위의 한계

- 부당한 대체근로에 해당하더라도, 노동조합이 이를 저지하는 방법은 법질서의 범위를 벗어나지 않아야 한다. "판례"는 노동조합이 부당한 대체근로를 문제 삼을 수 있으나, 물리력이나 위력을 행사하여 직접 저지하는 것은 정당한 쟁의행위로 보호될 수 없다고 본다. 즉, 법적 구제절차를 통하여 대응해야 하며, 물리적 방해는 업무방해죄, 강요죄 등 형사책임을 면할 수 없다.

## III. 사안의 적용

### 1. 대체근로 해당 여부

- C회사는 원래 A공사와 용역계약을 체결하고 있던 별도 회사이지만, 문제의 시점에 자사 근로자들을 새로이 투입하여 B회사 파업으로 생긴 공백을 메웠다. 이는 실질적으로 파업으로 인한 업무를 대신 수행하게 한 것으로서 "노동조합법 제43조"가 금지하는 대체근로에 해당한다 할 수 있다. 따라서 원칙적으로 부당한 사용자 행위라 할 수 있다.

### 2. 저지행위의 적법성

- 그러나 甲과 乙은 대체근로자들의 앞을 가로막고 퇴거를 요구하며 쓰레기를 복도에 버리는 등 물리력을 사용하였다. 이는 ❶ 대체근로자들의 근로권과 인격권을 침해하고, ❷ 업무수행을 방해하며, ❸ 폭행 · 협박 또는 위력에 해당할 수 있다. 따라서 형법상 업무방해죄, 강요죄의 구성요건에 해당한다.

### 3. 위법성 조각 여부

- 쟁의행위로서의 정당성이 인정된다면 위법성이 조각될 수 있다. 그러나 "판례"는 대체근로 저지를 위하여 물리적 수단을 사용하는 것은 정당한 쟁의행위로서 위법성이 조각되지 않는다고 일관되게 판시하고 있다. 따라서 甲과 乙의 행위는 쟁의행위의 목적은 정당하더라도 수단과 방법에서 정당성이 인정되지 않는다.

## IV. 결론

- 정리하면, C회사가 투입한 근로자는 실질적으로 B회사 파업에 따른 공백을 메우는 대체근로자에 해당하여 노동조합법상 금지되는 행위라 할 수 있다. 그러나 이를 이유로 노동조합 간부인 甲과 乙이 물리적 · 위력적 수단을 동원하여 대체근로자들의 작업을 직접적으로 방해한 행위는 정당한 쟁의행위로 보호될 수 없다. 이는 형법상 업무방해죄나 강요죄의 구성요건에 해당하고, 위법성이 조각되지 않는다. 따라서 甲과 乙의 행위는 형사적으로 위법하다고 평가함이 타당하다. 결론적으로 A공사와 C회사의 주장은 정당하다.